

1502359-39.2021.8.26.0024

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 06 horas, na Rua Dez, nº 1.081, Nova Canaã, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.12 e 15/17 dos presentes autos, tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 porção de "maconha", com peso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502359-39.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502359-39.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288859/2021 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 20976983 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2288859 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS HENRIQUE VIEGAS DOS SANTOS

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra MARCOS HENRIQUE VIEGAS DOS SANTOS imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 06 horas, na Rua Dez, nº 1.081, Nova Canaã, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.12 e 15/17 dos presentes autos, tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 porção de "maconha", com peso aproximado de 11,98g (cf. auto de contatação provisório de fls.37/40), além de cocaína, em quantidade não determinada, substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e Regulamentar. A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021, em decisão de fls.118/119. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.115/116.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória da prática de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28

da Lei 11.343/06.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/004 e boletim de ocorrência de fls. , termo de depoimento de fls.05/11; termo de interrogatório de fls.12/13; autos de exibição e apreensão de fls.32/33; fotografias de fls.34/35; laudos periciais de fls. 142/149), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido: Jonas Eduardo Canato, também policial civil disse que prestou apoio ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Chegando ao local, houve demora para a porta ser aberta, sendo que pôde constatar o réu dispensando algo na privada, o que se confirmou posteriormente ser droga. Também foi apreendida grande quantia em dinheiro, em considerando os rendimentos declarados pelo réu. Não sabe dizer a respeito de investigação prévia sobre os fatos, pois apenas prestou apoio à DISE. O policial civil, Jota Teodoro Coimbra narrou que foram cumprir mandado de busca na residência do réu, corroborando a versão do policial Jonas. Disse que havia informações prévias sobre a prática de tráfico pelo réu. Em diligências anteriores, notaram frequência constante na casas do réu, indicativa de tráfico. Relatou que a esposa do réu não sabia da existência dos valores em dinheiro apreendidos na residência.

A testemunha de defesa Eder Dias disse que o réu lhe prestava serviços em uma obra, como servente de pedreiro, ganhando cerca de R\$ 80,00 por dia. O réu também trabalhava por vezes aos sábados, ganhando R\$ 100,00. Na época dos fatos o réu lhe prestou serviços frequentemente.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que a maconha era para seu próprio consumo. Confirmou ter dispensado a cocaína no vaso, o que fez no momento do "desespero". Os valores que tinha era para pagamento do aluguel e do cartão de crédito.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese da análise dos elementos previstos em lei, conclui-se pela prática do tráfico de drogas, e não de mera posse de drogas para consumo pessoal.

Certo que os policiais indicaram terem realizado diligências prévias (com base na informação de fl. 07 dos autos em apenso - 1502271-98.2021), nas quais constataram grande frequência de pessoas na residência do acusado, o qual possui duas condenações definitivas recentes, uma por tráfico e outra por porte de arma.

A atitude do réu quando da chegada da polícia também é fator que deve ser levado em conta, pois inviabilizou a apreensão de outro tipo de entorpecente que havia na casa.

Some-se a isso o encontro de caderno com anotações não explicadas pelo réu (notadamente as de fl. 145) e o fato da companheira do acusado ter dito que não sabia da existência de valores na casa - foram apreendidos R\$ 1.545,00 em espécie no local. Ainda que verdadeira a versão de Eder, no sentido de que o réu vinha lhe prestando serviços, seria necessário que o réu não tivesse gasto qualquer valor das diárias recebidas naquele mês, o que se mostra basicamente impossível.

Em suma, considerando-se i) a existência de informações prévias (fl. 07 dos autos em apenso - 1502271-98.2021) e diligências indicativas da prática de tráfico; ii) o histórico criminal do acusado, com duas condenações recentes, sendo uma delas

também por tráfico; iii) a atitude do réu, que dispensou entorpecentes no vaso sanitário, inviabilizando a apreensão e aferição da quantidade da cocaína que havia no local; iv) o encontro de caderno com anotações típicas de quem pratica o tráfico; v) o próprio depoimento da esposa do réu, prestado na fase policial, dizendo desconhecer que o réu usasse drogas e também que estava em posse de tamanha quantidade de dinheiro, inexistem dúvidas de que o acusado praticava o crime descrito na denúncia.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJ TJ 101/498). Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau

de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($1/6$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $1/6$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de $1/8$ (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, valoro uma das condenações definitivas como antecedente criminal, e exaspero a pena-base em $1/8$, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito). Nesse passo, estabeleço a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente específico, o que demanda a exasperação em mais $1/6$, pelo mesmo modo de cálculo, o que conduz a reprimenda a 7 anos e 11 meses de reclusão e 791 dias-multa.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, tendo em vista os antecedentes do réu.

Sendo assim, a pena fica em 7 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 791 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e reincidência específica deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO MARCOS HENRIQUE VIEGAS DOS SANTOS, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 791 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e foi condenado a pena relativamente alta.

Formada sua culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que seja posto em liberdade. Anoto se tratar de acusado duplamente reincidente. Entendo assim, que permanecem os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens e valores apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 01 de fevereiro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)